

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0085037-83.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCELO SILVA SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Edison Tetsuzo Namba****VISTOS**

MARCELO SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque em 10.12.2016, por volta das 23 horas, na Rua Felice Giardini, 234, Jardim Ângela, São Paulo, trazia consigo, para fins de comercialização, 83 g de cocaína em 66 porções; 91,5 g de maconha, em 39 porções; 5,7 g de cocaína na forma de Crack, em 51 porções; e 71,5 g de lança-perfume, em 11 porções, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Segundo o apurado, Policiais Militares em diligência pelo local, avistaram o réu em atitude suspeita de tráfico e decidiram abordá-lo, encontrando dentro de uma sacola as drogas supracitadas, além da quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Foi determinada a notificação do réu em 9.8.2017 (fls. 92/94), sendo aquela efetivada (fls. 104), defesa prévia foi oferecida (fls. 107) e recebida a peça acusatória em 18.9.2017 (fls. 109/110), com instrução, interrogatório e debates.

O Ministério Público pediu a condenação, pois comprovados os fatos atribuídos ao réu, nos termos da peça acusatória.

O réu, por Defensoria Pública, pleiteou a redução da pena em 2/3, art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, incidência da confissão, regime inicial aberto e recurso livre.

É o relatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DE C I D O

A ação é procedente.

A *materialidade do delito* foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito de fls. 5/9, boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14, auto de constatação de fls. 15/17 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 96/98, cocaína, maconha, crack e lança-perfume foram apreendidos.

A *autoria* é atribuível ao réu.

No distrito, ficou em silêncio, fls. 9, respaldado em norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime (cf. **Apel. nº 1.245.929/0**, julgado em 19.3.2001, 11ª Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.

Jorge, policia militar, lembra-se do réu. Estava sozinho na prisão. Nas vestes havia droga – entorpecentes diversos (a quantidade era razoável). Não tentou fugir. Comentou fazer o tráfico. Não havia ninguém, era de madrugada. Estava com Pavani. Não lembra quem fez revista pessoal. Não se recorda de dinheiro. Ninguém interveio em seu favor. Local de ponto de tráfico. Em patrulhamento para coibir tráfico, localizaram-no. A área era carente, Praça próxima, por estar sozinho, foi abordado. Estava meio assustado. Já tinha visto o acusado, nada de ilícito foi localizado.

O policial, em depoimento coeso e uníssono, incrimina o réu, inexistindo razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública.

O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo princípio acima referido, da “legitimidade”. Em razão do princípio da legalidade, presumem-se praticados


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou, como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI, Diogenes. *Direito administrativo*. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).

Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. **Supremo Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus nº 74.251/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e **Habeas Corpus nº 73.518/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. **Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus nº 98766/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; **Habeas Corpus nº 130537/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; **Habeas Corpus nº 115510/SP**, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; **Habeas Corpus nº 38489/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e **Habeas Corpus nº 28417/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação nº 990.09.025057-7**, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Borges Pereira, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.150746-6**, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ribeiro dos Santos, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.056197-1**, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 993.04.076694-0 e 990.09.047692-3**, 13ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Lopes da Silva e Des. Cardoso Perpétuo, J. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.200330-5**, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 990.09.174019-5**, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Oliveira Passos, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 993.08.007218-3**, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. David Haddad, Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 990.09.173798-4 e 990.09.184274-5**, 9ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, na sequência, os Des. Penteado Navarro e Des. Galvão Bruno, Julg. 12.11.2009 e 29.10.2009; **Apelação nº 990.09.130107-8**, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203175-9**, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sydney de Oliveira Jr., Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 993.08.044297-5 e 993.05.075368-9**, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Machado de Andrade e Des. José Raul Gavião de Almeida, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203944-0**, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, Julg. 03.12.2009;


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Apelações ns. 990.08.051988-3 e 993.05.002085-1, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Augusto Siqueira e Des. William Campos, Julg. em 17.11.2009 e 24.11.2009; **Apelação nº 990.09.006709-8**, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; **Apelação nº 990.08.123484-0**, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009; **Apelação nº 990.09.219512-3**, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, Julg. 30.11.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

Em seu interrogatório, o **réu** declarou estar preso por tráfico. Tem 27 anos de idade. É primário. Confessa o tráfico. Precisava de dinheiro. Estava com maconha, cocaína, "crack" e lança-perfume. Não tinha dinheiro. Não sabe de quem é os R\$ 25,00. Estava com um rapaz, que inocentou. Está arrependido. Nada tem contra as pessoas do rol. Usava cocaína.

O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003, além de ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O *interrogatório* é tanto *meio de prova* como de *defesa*, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de *meio de defesa* e de *prova*, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (*Curso completo de processo penal*. 5ª ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151)

A confissão está em sintonia com as provas.

Em suma, o silêncio extrajudicial, confissão judicial, depoimento e apreensão provam o tráfico feito pelo acusado.

Doso as penas.

1ª fase


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Considerando a diretriz dos arts. 59 e 60 do Código Penal, circunstâncias judiciais, a primariedade do réu, o resultado e consequências do delito, normais se comparados com casos semelhantes, o grau de culpa, não intenso, os bons antecedentes do acusado, fixo a pena-base no mínimo, em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.

2ª fase

“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231 – STJ (...))” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a confissão não influi na pena.

Não há outras circunstâncias atenuantes e não há circunstâncias agravantes.

3ª fase

Tendo em vista ser primário, de bons antecedentes, não existindo prova de que participe de atividade ou organização criminosas, em razão do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, diminuo a pena de 1/2, para reprimi-lo e conscientizar-se dos malefícios de sua atitude para a sociedade, estando de posse de quantidade não desprezível de cocaína e maconha, tendo-se dois (2) ano e seis (6) meses de reclusão e duzentos e cinquenta (250) dias-multa.

Inexistem outras causas de diminuição e não há causas de aumento.

Pena final

A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica.

Regime de pena


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O regime inicial da pena corporal seria o aberto, por força do art. 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

O réu é primário, de bons antecedentes, jovem, preso com quantidade mediana de droga, em lugar conhecido para tanto, dessa maneira, em caso de descumprimento da pena substituta, é o melhor regime para repressão, prevenção especial e geral.

“Cícero, no "De Officiis", I, 58, dizia que o homem não pode ficar sozinho e, permanentemente procura companhia para falar e ouvir, ensinar e aprender, mesmo que, com uma espécie de varinha mágica, *quasi vírgula divina*, pudesse obter tudo o que quisesse, o homem é sócio do homem. Platão, na "República", II, 369, diz que a vida urbana é exposta como causada pela necessidade. Aristóteles, "Política", I, ao contrário, salienta que "animal político", *politikon zoon*, está para significar que o modo ideal de existência humana consiste em viver na *polis*, ou cidade-estado” - Antonio Junqueira de Azevedo. “Ciência do Direito, Negócio Jurídico e Ideologia”. *Estudos em homenagem ao professor Silvio Rodrigues*. São Paulo, Editora Saraiva, 1989, p. 18-19.

Não poderá alegar falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a necessidade de rever seus conceitos de licitude e necessidade econômica.

Sobre a possibilidade de escolha de regime mais benéfico no caso, especificamente aberto, cf. **RHC 113380/DF**, 2ª T. do STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 28.08.2012 e **HC 109583/MS**, 2ª T. do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 15.05.2012.

Deverá ser cumprida em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, sob as seguintes condições: a) permanecer no local que for designado pelo Egrégio Juízo das Execuções Criminais, durante o repouso e nos dias de folga; b) sair para o trabalho a partir das 06:00 horas e retornar ao local de permanência até às 20:00 horas; c) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia autorização judicial; d) comparecer àquele Juízo, trimestralmente, na data que lhe for assinalada, para informar e justificar suas atividades.

Valor do dia-multa


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias do réu (RT 705/338; JTACRIM 89/259 e 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2º, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, CONDENANDO o réu **MARCELO SILVA SANTOS**, qualificado nos autos, à pena de **dois (2) anos e seis (6) meses** de reclusão, **com regime inicial aberto**, mais **duzentos e cinquenta (250) dias-multa** do tipo secundário, na forma supramencionada, como incurso no **art. 33, "caput", c/c o § 4º do mesmo dispositivo legal, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal**.

Transitada esta em julgado, venham os autos conclusos, para designação de audiência de advertência. Após, remeter-se-á guia de recolhimento para o Juízo das Execuções.

O condenado tem direito de apelar em liberdade, nos termos do art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois primário, sem antecedentes e foi-lhe escolhido o regime aberto (domiciliar, de regra).

Nome no rol, oportunamente.

Não há montante de reparação mínimo, pela inexistência de prejuízo, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Decreto a perda dos valores encontrados com o réu, R\$ 25,00 e celular, fls. 12, com fulcro no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal promulgada em 5.10.88, e art. 63 e parágrafos 1º ao 4º da Lei nº 11.343/2006, pois produtos do crime.

Oficie-se para destruição da droga.

Sem custas, por ser patrocinado pela Defensoria Pública.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Publicada em audiência. R. I. e C., arquivem-se, no momento próprio.

São Paulo, 09 de novembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**